

刑法
No.341

R2-10 (配点: 2)

月	日
月	日

親族間の犯罪に関する特例について次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 甲が、実母乙の使用するタンスから、乙がその友人丙から預かり同タンスに保管していた丙所有の宝石を窃取した場合、甲の窃取行為について刑は免除されない。
2. 甲が、実父乙の内縁の妻である丙が乙から預かり保管していた乙所有の時計を窃取した場合、甲の窃取行為について刑は免除されない。
3. 甲は、家庭裁判所から実父乙の成年後見人に選任されていたところ、後見の事務として業務上預かり保管中の乙の預金を引き出して自己の借金の返済に充てた場合、甲の横領行為について刑は免除されない。
4. 甲が、友人乙を教唆して、乙の実父丙が所有し、管理している自動車を窃取させた場合、甲の窃盗教唆行為について刑は免除されない。
5. 甲が、同居していない祖父乙を恐喝して同人から現金の交付を受けた場合、甲の恐喝行為について刑は免除されない。

No341	親族間の犯罪	正答率
R2-10	正解	71%
	5	

1 正しい

甲の窃取行為には窃盗罪（235 条）が成立するところ、同罪には親族間の特例（244 条 1 項）が適用され得る。最決平 6.7.19 は、親族間の特例の適用範囲について、窃盗犯人と占有者・所有者双方との間に必要であるとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、窃盗罪の保護法益は占有であるとしても、究極的には所有権も保護することを否定するわけではなく、占有者所有者いずれの利益も尊重すべきであるということを挙げている。本記述の宝石の占有者は、甲の実母乙（直系血族）であるが、所有者は親族関係にない丙である。よって、甲について、親族間の特例（244 条 1 項）は適用されない。したがって、甲の窃取行為について刑は免除されない。

2 正しい ★

甲の窃取行為には窃盗罪（235 条）が成立するところ、同罪には親族間の特例（244 条 1 項）が適用され得る。しかし、最決平 18.8.30 は、244 条 1 項の「親族」について、内縁配偶者は含まれないとしている。その理由として、判例は、免除の範囲を明確に定める必要があるということを挙げている。本記述の宝石の所有者は、甲の実父乙（直系血族）であるが、占有者は内縁の妻であり、親族関係にない丙である。よって、甲について、親族間の特例（244 条 1 項）は適用されない。したがって、甲の窃取行為について刑は免除されない。

3 正しい

甲の横領行為には業務上横領罪（253 条）が成立するところ、同罪には親族間の特例（255 条、244 条 1 項）が適用され得る。最決平 24.10.9 は、最決平 20.2.18（百選Ⅱ35 事件）を引用し、「成年後見人が業務上占有する成年被後見人所有の財物を横領した場合、成年後見人と成年被後見人との間に 244 条 1 項所定の親族関係があっても、同条項を準用して刑法上の処罰を免除することができないことはもとより、その量刑に当たりこの関係を酌むべき事情として考慮するのも相当ではない」とする。理由として、「家庭裁判所から選任された成年後見人の後見の事務は公的性格を有するものであって、成年被後見人のためにその財産を誠実に管理すべき法律上の義務を負っている」ということを挙げている。本記述の甲は、実父乙と直系血族の関係にあるが、乙の成年後見人であるため、親族間の特例は適用されない。したがって、甲の横領行為について刑は免除されない。

4 正しい

244 条 3 項は、「前 2 項の規定は、親族でない共犯については、適用しない」と規定している。本記述の甲は、乙丙と親族関係にはないため、244 条 3 項により、親族間の特例（同条 1 項）の適用はない。したがって、甲の窃盗教唆行為について刑は免除されない。

5 誤っている

251 条は、「第 242 条、第 244 条及び第 245 条の規定は、この章の罪について準用する」と規定している。甲の恐喝行為には恐喝罪（249 条 1 項）が成立するところ、恐喝罪には親族間の特例が適用され得る（251 条、244 条 1 項）。244 条 1 項は、適用範囲について、「配偶者、直系血族又は同居の親族」と規定している。乙は、甲の祖父であり「直系血族」に当たる。よって、甲と乙が同居していなくても、親族間の特例の適用がある。甲の恐喝行為について刑は免除される。